

1500738-83.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Tem condenação por roubo, furto e tráfico, mas já cumpriu as penas. Informou que não conhecia a vítima, nem policiais. Está arrependido. O policial pisou na sua cabeça e outro na sobancelha.

A vítima Claudévan, na fase extrajudicial (fls. 12), informou que é proprietário do bar. Relatou que estava trabalhando quando os réus chegaram ao local e pediram água. Narrou que logo após ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500738-83.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500738-83.2022.8.26.0537 Controle nº 582/2022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID JHAMES DIAS OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

DAVID JHAMES DIAS OLIVEIRA e WESSITON SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, § 2.º, inc. II, (por três vezes), c.c. art. 70, ambos do Código Penal, porque no dia 13 de abril de 2022, por volta das 22:15 horas, no interior do estabelecimento comercial tipo bar, situado na Rua Maria Leonor, n.º 119, Centro, previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra as vítimas Claudévan dos Santos e Cleison José Soares, uma caixa de ferramentas e a quantia de R\$ 89,10 (oitenta e nove reais e dez centavos), pertencentes ao citado estabelecimento comercial, um relógio de pulso da marca Oscar, pertencente à vítima Claudévan, e um aparelho de telefonia celular da marca Samsung, de propriedade da vítima Cleison. As prisões em flagrante em prisão foram convertidas em prisões preventivas na

audiência de custódia (fls. 110/112).

Recebida a denúncia em 29.04.22 (fls. 139), os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 169/170). Na instrução criminal foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados.

Após a fase do art. 402 do CPP, a Dr.<sup>a</sup> Promotora de Justiça requereu a procedência da ação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela reincidência e fixação de regime fechado para ambos.

A Defensora Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação que seja reconhecido crime tentado, a fixação da pena no mínimo legal, que seja considerado crime único, as confissões judiciais, a participação de menor importância e fixação de regime diverso do fechado.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, os acusados permaneceram calados (fls. 14/15).

Em juízo, o réu David, confessou a prática do crime, dizendo que estava com o simulacro e o outro réu pegou os bens. O relógio era dele, quebrou e caiu. Afirmou que estava apenas com a caixa de ferramentas e o correu com dinheiro e celular das vítimas.

O réu Wessiton, em juízo, confessou a prática do crime, dizendo que o correu anunciou o assalto e ele entrou e pegou os objetos (dinheiro e celular). O relógio pertencia ao réu David. Tem condenação por dois furtos e já tinha cumprido a pena. Trabalhava o seu pai como ajudante de pedreiro. Praticou o crime para comprar drogas. Não conhecia a vítima, nem os policiais. Trabalhava como reciclador. Praticou o crime para pagar dívida de drogas do seu filho. Tem condenação por roubo, furto e tráfico, mas já cumpriu as penas. Informou que não conhecia a vítima, nem policiais. Está arrependido. O policial pisou na sua cabeça e outro na sobancelha.

A vítima Claudevan, na fase extrajudicial (fls. 12), informou que é proprietário do bar. Relatou que estava trabalhando quando os réus chegaram ao local e pediram água. Narrou que logo após tomarem água os réus anunciaram o roubo, exigiram os pertences de todos que estavam no local e depois mandaram que fossem para o banheiro do bar. Falou que pediu para os réus não levarem sua carteira. Então, os réus subtraíram uma caixa de ferramentas que estava no balcão do bar, seu relógio e quantia de R\$ 89,10. Afirmou que os réus também roubaram o telefone celular de um cliente do bar. Disse que depois que os réus se evadiram, avistou uma viatura passando pela rua, comunicou o roubo aos policiais e indicou os réus, que ainda estavam correndo pela via pública. Descreveu os autores como magros, de cor parda, sendo que um usava jaqueta vermelha e um mais alto que o outro. Informou que o autor mais alto utilizava um simulacro. Reconheceu os réus como autores do crime (fls. 68).

Em juízo, narrou que um homem sacou a arma, anunciou o assalto, o outro entrou em seguida, pegaram os bens e mandaram ir para o banheiro. Narrou que roubaram umas moedas do bar, um relógio dele e o celular da outra vítima. Os réus se evadiram, conseguiu sair do banheiro, chamou a viatura que passava e os policiais os detiveram. Presenciou a prisão. Reconheceu os réus na delegacia como os assaltantes pela fisionomia e roupas. Informou que um assaltante era alto e forte e outro mais baixo e franzino, ambos brancos. Nesta audiência reconheceu os réus (n.º 3- Wessiton- e 4-David). O réu David estava com máscara durante o assalto. Não viu se algum assaltante estava de relógio.

A vítima Cleison, na fase extrajudicial (fls. 13), relatou que estava no bar quando dois homens chegaram pedindo água. Narrou que os réus tomaram água e logo em seguida anunciaram o roubo, sendo que um deles apontou um revólver, e exigiram os pertences dos que estavam no local. Afirmou que, por receio, entregou seu telefone celular a um dos homens e foi para o banheiro do bar. Declarou que não tinha condições de reconhecer os autores do roubo porque ficou muito nervoso, mas que se recordava que o homem que estava armado era mais alto que o outro.

Em juízo, narrou que é cliente do bar, chegaram dois rapazes, um com arma, anunciaram o assalto e levaram seu celular, o qual foi recuperado. Na delegacia reconheceu os assaltantes. Foram trancados no banheiro, o dono do bar conseguiu

sair e a viatura prendeu os réus uns após 20 minutos. Narrou que um assaltante era moreno e outro branco com cabelo loiro. Não teve condições de reconhecer em juízo. Informou que o assaltante armado estava de boné e não viu se algum usava relógio. Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 09/11), disseram que realizam patrulhamento quando a vítima Claudevan acenou, informou que havia acabado de ser roubado e indicou dois homens que estavam correndo pela via. Relataram que avistaram os réus correndo em direção à Av. Leonor e foram no encalço deles. Narraram que enquanto corriam os réus dispensaram os bens subtraídos e um simulacro de arma de fogo. Falaram que quando alcançaram os réus estes resistiram à prisão e que o réu David entrou em luta corporal com eles, pelo que tiveram de algemá-lo. Informaram que foram ao pronto socorro e, posteriormente, apresentaram os réus no distrito policial.

Arthur (policial), em juízo, afirmou que estavam no contrafluxo do bar e viram saindo correndo do local dois homens, um com blusa vinho e outro com blusa preta e as pessoas acenando. Abordou o de blusa vermelha (David), que viu dispensando um simulacro. Os réus foram dispensando os bens durante a fuga. As vítimas reconheceram os réus. Localizaram os objetos (caixa ferramentas, saco com moedas, relógio dourado e celular Samsung), os quais foram reconhecidos pelas vítimas. Falou que o réu David resistiu à prisão.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Flávio. Narrou que abordou o réu Wessiton, que estava com blusa preta e o outro réu resistiu à prisão. As vítimas reconheceram os réus e os objetos apreendidos. Não viu os réus dispensando os bens, porque dirigia a viatura e fez retorno. Os réus confessaram. O fato das testemunhas serem policiais não as torna impedidas ou suspeitas (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

**"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:**

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP).

Assim, considerando as confissões judiciais, que a vítima Claudevan reconheceu os réus na fase extrajudicial (fls. 68) e em juízo, a apreensão da "res" (fls. 69 - kit de ferramentas, relógio pulso, R\$ 89,00 e celular Samsung) e do simulacro dispensados pelos réus e os depoimentos dos policiais (no sentido de que os viram saindo do bar com a arma na cintura e dispensando os bens das vítimas, que foram reconhecidos os réus e objetos) é caso de condenação.

Quanto ao concurso de agentes está demonstrado, uma vez que a prova produzida é no sentido de que o crime foi praticado pelos réus, enquanto o acusado Davi armado, abordou a vítimas, o corréu Wessiton permaneceu dando cobertura e pegou os bens, pelo que houve divisão de tarefas, não se podendo cogitar de participação de menor importância.

Não se trata de crime tentado, posto que empregada grave ameaça exercida com a utilização de simulacro de arma de fogo, houve inversão da posse e os réus tiveram a posse mansa e pacífica da "res", ainda, que por pouco tempo, posto foram detidos em local diverso, após diligência policial.

Nesse sentido é a Súmula 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

No caso em tela, foram roubados bens de três vítimas (Claudevan, do bar e de propriedade dele e da vítima Cleison), pelo que incide o concurso formal, uma vez que mediante uma ação foram violados os patrimônios de pessoas diversas. A alegação do réu David de que o relógio era de sua propriedade está isolada nos autos, uma vez que a vítima informou que foi subtraído o bem, o reconheceu e lhe foi entregue.

O entendimento de concurso formal nessa hipótese constitui corrente dominante, sendo inclusive o adotado pelo STF (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto e outros, Renovar, 7.<sup>a</sup> ed., p. 478).

Assim, impõe-se a condenação dos acusados, que segundo consta dos autos o réu David é reincidente (fls. 83 – proc. 1507360-72.2021; fls. 150 – proc. 19805-08.2008 – pena julgada extinta em 18.06.21; fls. 158/159 – proc. 55749-76.2005 – pena julgada extinta em 18.06.21), assim como o réu Wessiton é reincidente (fls. 95 – proc. 1525573-63.2020; fls. 96 – proc. 1500831-51.2019; fls. 96/97 – proc. 1502354-98.2019).

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

“O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

“Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)”. Portanto, a reincidência será considerada como circunstância agravante, posto que isso não é inconstitucional.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal fixo a pena-base dos réus em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Apesar das confissões judiciais considerando que os réus ostentam mais de uma condenação, inviável a compensação, mas serão consideradas no “quantum” de aumento da pena. Aumento as penas de 1/6, em razão da reincidência.

Aumento a pena de 1/3, por estar presente a qualificadora dos § 2.º, inc. II, do art. 157 do Código Penal.

Considerando que os acusados praticaram três roubos mediante uma só ação, incide a regra do concurso formal, pelo que, sendo as penas iguais, aumento a pena de 1/6 (sobre a pena já aumentada pela qualificadora), na forma do art. 70 do Código Penal.

O entendimento de concurso formal nessa hipótese constitui corrente dominante, sendo inclusive o adotado pelo STF (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto e outros, Renovar, 5.<sup>a</sup> ed. p. 328/329).

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, único compatível com a gravidade da conduta em concreto, pois o crime foi praticado com por dois réus, mediante grave ameaça com emprego de simulacro (fls. 207/209 – revólver acionado por ar comprimido), em um bar e durante horário e em local que há grande movimentação de pessoas e veículos, o que indica audácia e periculosidade dos agentes (art. 33, § 3.º, do Código Penal).

Ademais, os réus são reincidentes, pelo que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, “b” e “c” só se aplicam regimes mais brandos ao “condenado não reincidente”. As circunstâncias não são favoráveis, pois o acusado Daniel é reincidente específico (fls. 158/159 – proc. 55749-76.2005 – pena julgada extinta em 18.06.21), por furto qualificado (fls. 83 – proc. 1507360-72.2021) e por tráfico (fls. 150 – proc. 19805-08.2008 – pena julgada extinta em 18.06.21), e o réu Wessiton é triplamente reincidente por furto qualificado (fls. 95 – proc. 1525573-63.2020; fls. 96 – proc. 1500831-51.2019; fls. 96/97 – proc. 1502354-98.2019), o que demonstra que não foi um fato isolado em suas vidas e denota personalidades voltadas para crimes patrimoniais, pelo que não preenchem os requisitos da Súmula 269 do STJ (“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”).

Quanto ao dia-multa será à razão mínima em face da situação econômica dos réus.

A jurisprudência é no sentido de que o roubo é crime que traz intranquilidade à sociedade e coloca em risco potencial a vida da vítima, pelo que deve ser imposto o regime fechado, ainda que primário e independentemente da pena aplicada, pois isso não demonstra menor periculosidade e decorre de item independente de fundamentação interpretativa dos arts. 33, § 2.º e 59 do Código Penal (Ap. Criminal n.º 1.120.965.3/1, 5.<sup>a</sup> Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j.

08.11.07, Rel. Pinheiro Franco; Ap. Criminal n.º 1.079.453.3/2, 5.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 08.11.07, Rel. Tristão Ribeiro; STJ, 6.ª T., H.C. n.º 18.819/SP, cf. RT 806/486).

"Inexiste ilegalidade na escolha do regime fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime – o emprego de arma de fogo, a restrição da liberdade da vítima e o concurso de agentes, com periculosidade e destemor exacerbados, ainda que o agente seja primário e o quantum da pena – 5 anos e 8 meses de reclusão- seja inferior a oito anos (art. 33, § 3.º, do CP). Habeas Corpus não conhecido". (STJ, HC 282.211/SP, Rel. Ministro ROGERIO SHIETTI CRUZ, DJE 07.04.14).

"...o comando legal do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal não determina que o regime inicial tenha por baliza a pena-base fixada, e sim que o magistrado deva fundamentar sua sentença apoiado nas circunstâncias elencadas no art. 59 do mesmo Estatuto" (HC 295232/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6.ª Turma do STJ, DJE 09.03.15).

"A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da reprimenda" (STJ- 6.ª Turma, HC 262.939/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 08.04.14, DJE 25.04.14).

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenchem o lapso temporal para tanto (presos em 13.04.22 pelo que ainda que considerado 1/6 das penas só ocorreria em 27.06.23).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que conforme acima exposto o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a gravidade em concreto do crime, pelo que diante do concurso de agentes, utilização de simulacro, que foi confundido com arma verdadeira, em horário e local que há grande movimento de veículos e pessoas demonstrando audácia e periculosidade, e sendo os réus reincidentes em crimes patrimoniais (circunstância agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Em relação à alegação de agressão já foram adotadas as providências na audiência de custódia (fls. 47). Observo que segundo consta dos autos o réu resistiu à prisão, sendo necessária força para contê-lo e o corréu nada falou sobre os policiais agredirem aquele, pelo que nada há a ser deliberado a esse respeito por este juízo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO DAVID JHAMES DIAS OLIVEIRA e WESSITON SILVA à pena de 7 (SETE) ANOS, 3 (TRÊS) MESES e 3 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, com início no REGIME FECHADO e 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA à razão mínima, por se acharem incursos no art. 157, § 2.º, inc. II, (por três vezes), c.c. o art. 70, ambos do Código Penal.

Tendo em vista que os réus foram presos em flagrante, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes e para assegurar a aplicação da lei penal, posto nada há que os vinculem ao distrito da culpa (não comprovaram residência fixa nem ocupação lícita) e é incabível qualquer benefício, conforme inclusive decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, recomendem-se na prisão em que se encontram.

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos para as vítimas (art. 387,

inc. IV, do CPP com a redação da Lei n.º 11.719/08), porque a “res” foi recuperada (fls. 69).

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por serem beneficiários da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Quanto ao simulacro apreendido (fls. 69), já periciado (fls. 207/209), oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser dado o destino cabível.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome dos acusados no Rol dos Culpados. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 06 de julho de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA